



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/168/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן**

התובעת:

מירקין ברלב ענת, ת"ז
באמצעות ב"כ עו"ד שטרנברג סהר איתמר
רחוב נורדואו 3, ת.ד. 44486 חיפה 31444

נגד

הנתבעים:

1. **פסטחובה אולגה ת"ז**
2. **א. לוי השקעות ובניין בע"מ ח.פ.**
3. **לוי עזרא ת"ז**
4. **לוי אברהם ת"ז**
5. **עזרא כהן**

נתבעים 2-5 באמצעות ב"כ עו"ד לוי טל
רחוב חורב 30, חיפה

6. **מניס רימה ת"ז**
7. **טריקי יעקב ת"ז**
8. **שבתאי יאיר ת"ז**
9. **גולדנברג אלאונורה ת"ז**
10. **פינסקי אלה ת"ז**

נתבעות 9 ו-10 באמצעות ב"כ עו"ד נחשון רון
שדרות מוריה 131, חיפה

11. **גונופולסקי איגור ת"ז**

פסק דין

בתביעה שלפניי מבקשת התובעת להצהיר על זכותה בניצול אחוזי הבנייה המוקנים לבית המשותף לצורך בנייה על שטח הגג המוצמד לדירתה.

ההליך התנהל לפני כב' המפקח (כתוארו אז) יובל וסרקרוג, אשר מונה לשיפוט בערכאה אחרת; בהחלטתו האחרונה מיום 16.12.20 ניתן תוקף להסדר דיוני בין הצדדים בדבר הגשת סיכומים בכתב ללא צורך בשמיעת ראיות.

מכוח סעיף 75(ב) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 ראיתי להמשיך בניהול התיק מהשלב הנוכחי, וליתן פסק דין על יסוד סיכומי הצדדים והחומר שהוגש לתיק.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/168/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הצדדים, הרקע העובדתי והמחלוקת

מדובר בבית משותף שנמצא ברחוב נורדאו 28 בחיפה, וידוע כגוש 10862 חלקה 74. הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים בשנת 1959 (להלן - **הבית**).

התובעת בעלת הזכויות בת"ח 13 מכוח הסכם מכר מיום 29.3.2018 שנחתם בינה לבין המוכרות א.ד. תאנא בע"מ ושלוש תל אביב בע"מ (להלן - **בעלי הזכויות הקודמים**). מצו רישום הבית המשותף עולה כי מדובר ביחידת מחסן בקומת הגג של הבית, ששטחה 8.10 מטר; ליחידה מוצמד גג המסומן בתשריט הבית באות ג' (להלן - **הגג המוצמד**) וחלקה ברכוש המשותף הוא 8/562.

הנתבעים הם בעלי הזכויות בדירות שבבית המשותף, לפי הפירוט הבא:

נתבעת 1 - ת"ח 1; **נתבעת 2** - ת"ח 2, 4 ו-5; **נתבעים 3-5** - ת"ח 3 ו-5; **נתבעת 6** - ת"ח 6; **נתבע 7** - ת"ח 7; **נתבע 8** - ת"ח 8; **נתבעת 9** - ת"ח 10; **נתבעת 10** - ת"ח 11; **נתבע 11** - ת"ח 12.

בעת רישום הבית, חתמו בעלי הקרקע על תוספת להסכם המצוי לפי חוק הבתים המשותפים תשי"ג-1952, שחל אותה העת. בסעיף 1 לתוספת להסכם המצוי (להלן - **התקנון**) נקבעה זכותם של בעלי ת"ח 13 לבנות על הגג המוצמד, ובמוקד המחלוקת בין הצדדים עומדת שאלת פרשנותו של סעיף זה בדבר היקף זכותם של בעלי ת"ח 13 לבנות על הגג המוצמד (ראה להלן).

בין השנים 2012 עד 2016 ניהלו בעלי הזכויות הקודמים הליכים ברשויות התכנון והבנייה, לצורך קבלת היתר בנייה על שטח הגג המוצמד, ובחודש 3/2016 נדחתה הבקשה מהטעם שלא הוכחה זכותם הקניינית של בעלי הזכויות הקודמים לבנות על הגג המוצמד, ואלו הופנו לערכאה המשפטית המוסמכת לדון בסוגיה זו (ראו: נספח ג לכתב התביעה).

בשנת 2018 רכשה התובעת את הדירה מבעלי הזכויות הקודמים ובחלוף שנה לערך, ביום 17.3.2019 הוגשה התביעה שלפניי.

יריעת המחלוקת

כאמור, במרכז המחלוקת עומדת שאלת פרשנותו של סעיף 1 לתקנון הקובע את זכותם של בעלי הזכויות בתת-חלקה 13 לבנות על שטח הגג המוצמד:

**"בעלי הדירות של הבית המשותף הבנוי על החלקה 74 בגוש 10862 מבקשים
בזה לרשום בתור תוספת להסכם המצוי את הדברים כדלקמן: -**

1. **הוסכם בזה בין כל בעלי הדירות כי לבעלי היחידה מס' 74/13 תהיה הזכות בכל עת, לאחר שיקבלו רשיון לכך מהרשויות המוסמכות להקים מבנה או מבנים על שטח הגג הצמוד ליחידה מס' 74/13 או**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/168/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**על חלק ממנו, ולצרף, ללא כל תשלום, את המבנה ו/או המבנים
לרשת וצנורות החשמל, לרשת וצנורות המים וכל סדורים כלליים
אחרים בבית ללא כל צורך בקבלת הסכמת בעלי יתר הדירות..."**

מכוח הוראה זו שבתקנון, מבקשת התובעת להורות על זכותה בניצול מלוא אחוזי הבנייה המוקנים לבית המשותף או למצער בניצול אחוזי הבנייה הנדרשים לשם בנייה על שטח הגג המוצמד לדירתה. מנגד, נטען ע"י חלק מהנתבעים כי לתובעת אין זכות ייחודית בגג המוצמד ויש שטענו כי זכותה לבנות על הגג מוגבלת בהתאם לחלקה ברכוש המשותף. לחלופין, נטען שזכות התובעת לבנות מותנית בתשלום תמורה ליתר בעלי הדירות.

ההליכים בתיק

כתב תביעה הוגש ביום 17.3.2019 נגד 15 נתבעים. בשל פטירתם של חלק מהנתבעים וקושי להתחקות אחר זהות יורשיהם, ניתנה לתובעת רשות לתקן את כתב התביעה והוא תוקן פעמיים, על דרך של שינוי בעלי הדין (הנתבעים); עובדות כתב התביעה המקורי כמו גם נספחיו, לא שונו.

ביום 3.2.2020 הוגש כתב התביעה המתוקן בשנית, הוא כתב התביעה האחרון שהוגש, שאליו יתייחס פסק דין זה (להלן – **כתב התביעה**), אם כי ההפניות בפסק הדין לנספחי כתב התביעה מתייחסות לנספחים שצורפו לכתב התביעה המקורי שהוגש.

ביום 1.5.2019 הוגש כתב הגנתם של נתבעים 2-5.
ביום 10.6.19 הוגש כתב הגנה מטעם נתבע 8 (כתב הגנתו נושא את הכותרת "כתב הגנה מטעם הנתבע מס. 10" (מספרו של נתבע 8 בכתב התביעה המקורי).
ביום 12.6.2019 הוגש כתב הגנה מטעם נתבעות 9-10 (כתב ההגנה נושא את הכותרת "כתב הגנה מטעם הנתבעים 13 ו-14" מספרן של נתבעות אלו בכתב התביעה המקורי).
נתבע 7 הודיע ביום 11.3.2020 כי אינו מתנגד לאמור בכתב התביעה.
לא הוגשו כתבי הגנה מטעם יתר הנתבעים.

התיק נקבע לישיבת הוכחות מספר פעמים ובוטל לבקשת הצדדים מסיבות שונות, בין היתר ניסיונות לגבש הסכמות מחוץ ללשכת המפקחת. ביום 24.3.20 ניתן לבקשת התובעת, צו לעיון והעתקת מסמכים (לעיריית חיפה וללשכת רישום המקרקעין) שמטרתו בין היתר הייתה להתחקות אחר זהותם של עורכי מסמכי הבית המשותף, אלא שצווים אלו לא הועילו, משמדובר בתקנון משנת 1958 ובהעדר פרטים נוספים של עורכיו לבד משמם (ראו הודעת התובעת מיום 15.6.21).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/168/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בתיק התקיימה ישיבת קדם-משפט ביום 19.12.2019 שבה נכחו התובעת ובא כוחה, ב"כ נתבעים 5-2 ונתבעות 9-10. בדיון נוסף שנקבע ליום 8.12.20 התייצב רק בא כוח נתבעות 9 ו-10 (בשל טעות, לא דאג הנ"ל לזימונם של יתר הצדדים). בדיון זה הודיע ב"כ נתבעות 9 ו-10 על ניסיון לקדם הסדר דיוני עם התובעת, הכולל גם את נתבעים 5-2. בהתאם לכך ניתנה החלטה המורה לצדדים להודיע עד ליום 25.12.20 האם הגיעו להסכם דיוני.

ביום 15.12.20 הוגשה הודעת ב"כ נתבעות 9 ו-10 שמאופן ניסוחה עולה כי הוגשה גם בשם התובעת ובשם נתבעים 5-2. בהודעה נכתב כי הוסכם שהנתבעים יעבירו שאלון לתובעת (להלן – **השאלון**), עליו תשיב בתצהיר. עוד הוסכם, שהתובעת תגיש סיכומיה בכתב, לאחריהם יוגשו סיכומי הנתבעים, ופסק הדין יינתן על-סמך החומר שמצוי בתיק.

ביום 03.01.21 הוגשו סיכומי התובעת, וביום 09.03.21 הוגשו סיכומי נתבעות 9 ו-10, ש אליהם צורף השאלון ותצהיר תשובות התובעת.

משלא הוגשו סיכומים מטעם נתבעים 5-2 ואף לא הוגשה כל הודעה או בקשה מטעמם, ניתנה ביום 18.4.21 ארכה להגשת סיכומים, בעקבותיה הוגשו סיכומי נתבעים 5-2.

טענות הצדדים בתמצית

טיעוני התובעת

לטענת התובעת, בתקנון נקבעה זכותה לבנות על הגג המוצמד, לשם כך רשאית היא לנצל את זכויות הבנייה המוקנות לבית המשותף. לטענת התובעת, הצמדת הגג לדירתה למטרת בנייה כוללת את הזכות לנצל את אחוזי הבנייה בשיעור הנדרש לשם מימוש זכות הבנייה שהוקנתה לה.

טיעוני נתבעים 5-2

נתבעים 5-2 טוענים לשיהוי בהגשת התביעה אשר דינו להביא לדחיית התביעה, וכן להשתק, מניעות וויתור, שכן היה על התובעת לדעת כי ישנו נוהג מושרש בין בעלי הדירות בבית, בקשר לבעלות בגג, וגם אם לא בא זכרו של נוהג זה בדרך של תיקון צו רישום הבית המשותף, הרי שבירור עובדתי, כמו ביקור בבית המשותף קודם לרכישה, היה מעיד בפני התובעת, שהלכה למעשה נוהג הבעלות שונה מנסח הרישום.

לטענת נתבעים 5-2, התובעת אשר רכשה את דירתה במהלך השנים האחרונות (שנת 2018) מבקשת לשנות סדרי בראשית הנוהגים בין כלל בעלי הדירות בבית המשותף מזה עשורים, אלו משקפים זכויות מלאות ושוות של כל בעלי הדירות בגג הבית כולו, לרבות שטח הגג המוצמד רישומית לתת-חלקה 13. לטענת נתבעים 5-2, בעבר דרשו בעלי הזכויות הקודמים מיתר בעלי הדירות להשתתף



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/168/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בעלויות תחזוקת הגג המוצמד, דבר המוכיח שגם בעלי הזכויות הקודמים לא ראו בגג המוצמד כשטח שבבעלותם הייחודית.

לטענת נתבעים 2-5 ככל שתיקבע זכותה של התובעת לנצל את אחוזי הבנייה של הבית לצורך בנייה על הגג המוצמד, הרי שהדבר מותנה בתשלום תמורה מצדה ליתר בעלי הדירות. מלשון התקנון עולה שבמקום שבו ויתרו בעלי זכויות על תמורה, צוין הדבר מפורשות בתקנון (כך למשל ביחס לויתור בעלי הדירות על תשלום עבור חיבור המבנים שיוקמו על הגג המוצמד לתשתיות החשמל, המים והביוב), ואילו ביחס לזכויות הבנייה, לא צוין במפורש ויתורם של בעלי הדירות, ואין לקרוא לתוך התקנון מה שאינו קיים. הצמדת הגג וניצול אחוזי בנייה הם שני דברים שונים, ואין בעצם הצמדת הגג לת"ח 13 כדי לקבוע שעם הצמדת הגג לת"ח 13 הוקצו ללא תמורה גם זכויות בנייה.

טענות נתבע 8

כתב הגנתו של נתבע 8 זהה לכתב הגנתם של נתבעים 2-5. יש לראות בדיון בטענות נתבעים 2-5 כדיון בטענותיו של נתבע 8.

טענות נתבעות 9 ו-10

נתבעות 9 ו-10 אינן כופרות בזכויותיה של התובעת בגג המוצמד ואף אינן חולקות על כך שבתקנון הוקנתה לתובעת הזכות לבנות על הגג המוצמד. הגנת נתבעות 9-10 מתמקדת בסוגיית היקף אחוזי הבנייה המוקצים לתובעת לבנייה על הגג המוצמד ולטעמן, אלו מוקנים לה, על פי חלקה היחסי ברכוש המשותף.

עוד טוענות נתבעות 9 ו-10 כי לפי הוראת הוועדה המקומית, היה על התובעת להוכיח שכוונת הצדדים הייתה להקנות לבעלי הזכויות בתת-חלקה 13 את מלוא זכויות הבנייה של הבית המשותף לשם בנייה על הגג המוצמד, אך חלוף הזמן ממועד עריכת התקנון מקשה להתחקות אחר אומד דעת הצדדים, ומשכך, לא הרימה התובעת את נטל ההוכחה בעניין זה. מעבר לכך ציינו הנתבעות 9-10 כי על התובעת היה לבדוק את המצב לאשורו, טרם ביצוע הרכישה, אך היא נמנעה מלעשות כן.

דיון והכרעה

ראשית, אציין כי לא הוכחה לפניי טענת הנתבעים 2-5 לקיומו של שיהוי המצדיק את דחיית התביעה. כאמור, בשנת 2018 רכשה התובעת את הדירה מבעלי הזכויות הקודמים, וכשנה לאחר מכן הוגשה התביעה שלפניי, שעניינה הכרעה בשאלת זכותה הקניינית של התובעת לבנות על הגג המוצמד. זאת עשתה התובעת בהתאם להחלטת רשויות התכנון מחודש 3/2016 שדחתה את הבקשה להיתר שהוגשה על ידי בעלי הזכויות הקודמים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/168/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לצורך הוכחת שיהוי, אין די בחלוף הזמן - ואיני קובעת כי תנאי זה התקיים בין היתר בשל קביעת התקנון את הזכות לבנות "בכל עת" - ועל הטוען לשיהוי להוכיח גם כי שינה מצבו לרעה (ראו: ע"א 6805/99 **תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה ירושלים**, פ"ד נז(5) 433(2003)), תנאי זה לא נטען וממילא לא הוכח.

לגופו של עניין, ובטרם אפנה לדיון בשאלת פרשנותו של התקנון העומדת במרכז המחלוקת, אתייחס לטענת נתבעים 2-5 כי לתובעת אין זכות בלעדית בגג המוצמד, אלא זכות שווה (שלא נטען מהי – ע"מ) לזכותם של יתר בעלי הדירות. טענה זו באה לידי ביטוי בסעיף 1.7 לכתב הגנת נתבעים 2-5: **"נוהג בעלי הזכויות על פני עשורים, התנהלותם והתנהגותם היו כאלה ששיקפו זכויות מלאות ושוות בגג הבית כולו – בין שהוא גג תת חלקה 13 ובין שהוא גג הבניין ככלל הצמוד פיזית ומוצמד (רישומית) לתת חלקה 13"** (ראו גם ס' 3.2 ו-4.5 לכתב ההגנה).

בסעיף 4.5 לכתב הגנתם מציינים נתבעים 2-5 כי לאורך השנים נשאו כל בעלי הדירות בבית המשותף בהוצאות תחזוקת הגג, לרבות הגג המוצמד. לביסוס טענתם מפנים נתבעים 2-5 לפסק דין שניתן ביום 8.12.2013, בשלוש תביעות (שאוחדו) שהגישו בעלי הזכויות הקודמים נגד יתר בעלי הדירות בבית. בפסק הדין שצורף לסיכומי נתבעים 2-5, מתואר הבית המשותף כדלקמן:

"מבנה בן 5 קומות ובו 13 יחידות...בקומה העליונה ישנה יחידה אחת בלבד בשטח של 8.1 מ"ר מתוארת כמחסן והיא בבעלות התובעות. החלקים היחסיים של כל דירה ברכוש המשותף נגזר משטחה. 4 מתוך 5 היחידות בקומת הקרקע מוגדרות כחנויות. הגג מחפה על כל הקומה הרביעית מוצמד למחסן הבנוי עליו, היינו נתון בבעלות התובעות. הגג המחפה על המחסן הוא רכוש משותף. טוענות התובעות כי מאחר והן חוייבו ע"י הרשות המקומית לפרק את גג הבטון שחיפה על היחידה שלהן [להלן: "המחסן"] בתוקף חוקי עזר למבנים מסוכנים, ומשהתברר להן כי הגג הינו רכוש משותף, הן מבקשות להיפרע מכל בעלי הדירות כשיעור חלקו של כל אחד מהם ברכוש המשותף..."

הנה כי כן, פסק הדין עליו סומכים נתבעים 2-5 את טענותיהם מתייחס לשני גגות: **גג אחד**, המחפה על שטח הקומה הרביעית, הוא הגג המוצמד שבבעלות התובעות, **וגג שני**, המחפה על יחידה 13, המהווה רכוש משותף.

בניגוד לטענת נתבעים 2-5, מקריאת פסק הדין אין ספק כי תביעתם של בעלי הזכויות הקודמים בת"ח 13 לחייב את בעלי הדירות להשתתף בתחזוקת הגג לא התייחסה לגג המוצמד, אלא לגג השני המהווה רכוש משותף, אשר בשל טעות נשאו בעלי הזכויות הקודמים בהוצאות אחזקתו:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/168/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

"...ומשהתברר להן כי הגג הינו רכוש משותף, הן מבקשות להיפרע מכל בעלי הדירות כשיעור חלקו של כל אחד מהם ברכוש המשותף".

מעבר לכך שטענת הנתבעים 2-5 נמצאה עובדתית לא נכונה, הרי שגם לו היה מוכח שבמקרה מסוים השתתפו בעלי הדירות בתחזוקת הגג המוצמד כמתואר, לא היה בכך כדי לשנות מזכויותיהם של בעלי הזכויות בגג המוצמד, ולהפוך את יתר בעלי הדירות לשותפים שווי זכויות בגג המוצמד, כפי שטוענים נתבעים 2-5. הנתבעים אמנם אינם מציינים אילו זכויות יש להם בגג המוצמד וטיעוניהם בדבר היותם בעלי זכויות בגג המוצמד נטענו באופן מעורפל ובכלליות. ברי, כי אין בטענה זו ממש. משהוצמד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, דינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד (סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין), ביטול הצמדה מהווה עסקה במקרקעין, דורש את הסכמת כל בעלי הדירות ואינו נעשה אגב אורחא. יצוין כי מעבר למקרה זה לו טוענים נתבעים 2-5, שבו לכאורה דרשו בעלי הזכויות הקודמים את השתתפותם של יתר בעלי הדירות בתחזוקת הגג המוצמד, לא טענו נתבעים 2-5 למקרים נוספים, שמהם ניתן להסיק על "נוהג בעלי הזכויות על פני עשורים, התנהלותם והתנהגותם היו כאלה ששיקפו זכויות מלאות ושוות" בגג המוצמד (סעיף 1.7 לכתב הגנת נתבעים 2-5).

יצוין כי בפסק הדין נדחתה תביעת בעלי הזכויות הקודמים לשיפוי ההוצאות שהוציאו לתחזוקת הגג המשותף, משלא התקיימו מלוא התנאים שנקבעו בפסיקה בעניין זה (אז חלה הלכת רוס שנקבעה בע"א 179/84 רוס נ' חפציבה, פ"מ תשמ"ה (ג) 418 (1985)). מעבר לדחיית התביעה הכספית, נדחתה בפסק הדין תביעת בעלי הזכויות הקודמים לסילוק גגוני פח של דירה אחרת שהיו מעוגנים לגג המוצמד, משנקבע כי נכון לאותה העת, לא היה בגגוני הפח להגביל או לפגוע בזכותם הקניינית של בעלי הזכויות הקודמים בגג המוצמד. אם כן, גם חלקו זה של פסק הדין מאשר את זכויותיה של התובעת שלפניי בגג המוצמד, בניגוד לטענת נתבעים 2-5.

מהנימוקים שהובאו לעיל, נדחת טענת נתבעים 2-5 בדבר זכויותיהם של יתר בעלי הדירות בגג המוצמד.

מכאן, נפנה לבחון את השאלה המרכזית העומדת להכרעה, והיא האם ההוראה בתקנון המתירה לתובעת לבנות על שטח הגג המוצמד לדירתה, כוללת גם הסכמה לנצל את אחוזי הבנייה המוקנים לבית המשותף, ואם כן, באיזה היקף.

לצורך הדיון בשאלת הפרשנות שיש לתת לתקנון, תובא להלן סקירה קצרה של ההלכות הנוגעות למעמדן של זכויות הבנייה בבית משותף ולדרכים להקנייתן על פי הוראות הדין:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/168/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המונח "זכויות בנייה" או "אחוזי בנייה" משמעותו "אפשרות ניצול הקרקע לבנייה על-פי הדין" (רע"א 2821/95 לוסטיג נ' מייזלס, פ"ד (1) 517, 527 (1996); ע"א 3451/07 קאופמן נ' כהן (נבו), 18.2.2010).

בפסיקה נקבע כי זכויות בנייה אינן חלק מהרכוש המשותף, אלא נכס בעל ערך כלכלי המצוי בבעלות משותפת של כל בעלי הדירות בבית המשותף. ככל שלא הוסכם אחרת, לכל בעל דירה חלק בזכויות הבנייה של הבית המשותף בהתאם לחלקו היחסי ברכוש המשותף; לפיכך, גריעה של חלק מסוים מהרכוש המשותף והצמדתו לדירה מסוימת, אין משמעה מתן זכות בנייה "אוטומטית" על אותו חלק שהוצמד. במילים אחרות: אין לראות בהצמדה של שטח כלשהו לדירה מסוימת, כאילו היא כוללת גם את הזכות להשתמש בזכויות הבנייה הקיימות לשם בנייה על אותו חלק שהוצמד אליה (ע"א 136/63 לווינהיים נ' שורצמן, פ"ד יז' 1722, 1727 (1963); ע"א 239/79 גלבורט נ' הממונה על המרשם, פ"ד לד(2), 807; ע"א 19/81 ביבי נ' הורברט, פ"ד לו(2), 497 (1983); ע"א 432/83 מזרחי נ' חביב, פ"ד מ(4), 673 (1986); ע"א 7156/96 שואעי נ' בכרך, פ"ד נג(1), 469, 476 (1999)).

על-פי הפסיקה, ניתן להתנות על זכויות בנייה בהסכמות חוזיות (ע"א 11965/05 עזבון המנוח מרדכי קליין נ' שרון (נבו), 27.8.2009); הסכמה חוזית יש לעגן בדרך של רישום בפנקסי המקרקעין או בדרך של רישום ההסדר החוזי בתקנון המוסכם (ע"א 10322/03 ישעיהו נ' שטרייכר, פ"ד נט(6) 449 (2005)).

ניתן להסיק על הסכמה להקנות זכויות בנייה מן הנסיבות ואין הכרח בהסכמה מפורשת דווקא. בע"א 19/81 שאוזכר לעיל נפסק: **"... בעלי הדירות בבית המשותף יכולים להסכים או להשלים עם שלילת זכויות בנייה מהם והעברת הזכות לאחד מהם, אם בהתנאה בתקנון המוסכם לבית המשותף ואם בתנאים מוסכמים בחוזים אישיים רגילים, או בדרך נאותה אחרת...אם הצמדת חלק מהרכוש המשותף לדירה פלונית כוללת בחובה גם את זכויות הבנייה על אותו רכוש, ואם בעלי הדירות האחרים הסכימו להצמדת זכות זו לפלוני ושלילתה מאחרים - אלה הן שאלות שבעובדה, הצריכות הוכחה...ההוכחה אפשר שתמצא במסמך הרישום בלשכת רישום המקרקעין, ואפשר שתתגלה ותעלה מתוך ראיות אחרות כגון: חוזים שנחתמו עם בעלי הדירות, הצהרות שהצהירו וכיוצא באלה ראיות, שיש בהן כדי לשכנע את בית המשפט ולהשכילו באשר לכוונות הצדדים בדבר זכויותיהם בנכס, לרבות ברכוש המשותף ובזכויות הבנייה..."**

הנה כי כן, הצמדת גג משותף לדירה מסוימת איננה כוללת מאליה, גם הסכמה לבנייה על הגג שהוצמד או לניצול אחוזי הבנייה הנדרשים לשם בנייה על גג זה (ע"א 136/63; ע"א 749/96 וע"א 239/79 שאוזכרו לעיל). בשונה מכך, נקבע בפסיקה כי מתן הסכמה לאחד מבעלי הדירות לבנות על הגג, כוללת גם הסכמה לניצול אחוזי הבנייה, בהיקף הנדרש לשם בנייה על גג זה, ולא מעבר לכך. בהקשר זה ראה דברים שנאמרו בע"א 5043/06 גלמן נ' הררי-רפול, פ"ד נד(3) 389: **"הדעת נותנת,**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/168/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כי ההיתר שניתן בתקנון לבעלי הדירה לבנות על הגג הצמוד לדירתם כולל בחובו אף הסכמה לשימוש באחוזה הבניה של הבניין".

יובהר כי בפסק הדין גלמן, לא עלה ספק בדבר הזכות לניצול אחוזי הבנייה כזכות אינהרנטית מכוח הסכמה לבנייה, שעוגנה בתקנון, והמחלוקת נסבה סביב השאלה, האם הסכמה לבנייה מהווה הסכמה לניצול **מלוא** אחוזי הבנייה שנותרו לבניין, גם אם אלו עולים על אחוזי הבנייה הנדרשים לבניית קומה אחת. וכך נאמר בהמשך הדברים: "...ההיגיון הכלכלי מחייב לפרש את ההיתר שניתן לבנייה על הגג הצמוד לדירה ככולל בחובו אך ורק את אחוזי הבנייה המספיקים להקמת קומה אחת..."

בפסק-הדין מזרחי שאוזכר לעיל, נאמר: "כאשר הסכים המשיב, שהמערער יבנה על הגג, הסכים לאפשר למערער להשתמש באחוזה הבנייה של הבניין. הסכמה כזו לבנייה, שניתנה מראש, די בה, ואין צורך בהסכמה נוספת".

בע"א 239/79 שאוזכר לעיל נפסק בהקשר זה: "במקרה שבפנינו כלל התקנון לא רק הסכמה מראש להצמדה אלא גם הסכמה מראש לבניה על הרכוש המוצמד ועל כן לא היה המערער זקוק להשגתה של הסכמה נוספת בנושא זה, מעבר למה שנאמר בתקנון. אלמלא זאת היה כאמור נזקק להסכמה נפרדת של בעלי הדירות לבניה על אף קיומה ותקפותה של ההסכמה להצמדה".

מסקנת הדברים עד כה, הצמדת גג כשלעצמה אינה כוללת אינהרנטית גם את הסכמת בעלי הדירות לבנייה על אותו גג. בשונה מזאת, הצמדת גג לצורך בנייה על אותו גג, מהווה הסכמה לנצל את זכויות הבנייה לשם בנייה על אותו גג, גם אם לא צוין במפורש שניתן לנצל את אחוזי הבנייה של הבית המשותף לשם כך. הזכות לנצל את אחוזי הבנייה מוגבלת למימוש זכות הבנייה שניתנה, ולא מעבר לכך.

מכאן נפנה לבחון את הוראת התקנון המורה על הצמדת הגג ליחידה 13 שבבעלות התובעת. תקנון הבית המשותף, מהווה הסכם בין בעלי הדירות לבין עצמם. משנרשם התקנון בפנקס הבתים המשותפים, ניתן לו מעמד קנייני, והוראותיו מחייבות את כל בעלי הדירות וחליפיהם החוקיים (סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין; א. אייזנשטיין, **יסודות והלכות בדיני מקרקעין** (בתים משותפים) (בורסי, תשס"א-2001, עמ' 132-133).

ככל הסכם יש לפרש את התקנון לפי אומד-דעת הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין; ככל שאומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו. היה ולא ניתן להתחקות אחר אומד דעתם הסובייקטיבי של הצדדים, יש לבחון את תכליתו האובייקטיבית של החוזה, המושפעת בין היתר מעקרון תום הלב, משיקולי היגיון, מיעילות עסקית ומשכל ישר (ראו: דנ"א 2045/05 מגדלי הירקות – אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד סא(2) 1 (2006); ע"א 8239/06 **אברון נ' פלדה** (נבו, 21.12.2008)).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/168/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

להלן הנוסח המלא של התוספת לתקנון:

**"בעלי הדירות של הבית המשותף הבנוי על החלקה 74 בגוש 10862 מבקשים
בזה לרשום בתור תוספת להסכם המצוי את הדברים כדלקמן: -**

1. **הוסכם בזה בין כל בעלי הדירות כי לבעלי היחידה מס' 74/13 תהיה הזכות בכל עת, לאחר שיקבלו רשיון לכך מהרשויות המוסמכות להקים מבנה או מבנים על שטח הגג הצמוד ליחידה מס' 74/13 או על חלק ממנו, ולצרף, ללא כל תשלום, את המבנה ו/או המבנים לרשת וצנורות החשמל, לרשת וצנורות המים וכל סדורים כלליים אחרים בבית ללא כל צורך בקבלת הסכמת בעלי יתר הדירות.**
2. **הוסכם כמו כן בין כל בעלי הדירות כי לאחר הקמת המבנה ו/או המבנים יהיו בעלי היחידה מס' 74/13 רשאים לבקש לבד, מבלי שיצטרכו הסכמה של בעלי היחידות האחרים, תקון צו רשום הבית המשותף על מנת שאפשר יהיה לכלול בצו את הדירות הנוספות. בעלי כל הדירות מסכימים בזה כי כתוצאה מתיקון צו רשום הבית יחולו שנויים בחלקים ברכוש המשותף הצמודים לכל יחידה ויחידה".**

מלשון התקנון עולה ברורות כי לבעלי יחידה 13 הוקנתה זכות לבנות "מבנה או מבנים על שטח הגג הצמוד...או על חלק ממנו". לנוכח המסגרת הנורמטיבית שפורטה לעיל, הצמדת גג למטרת בנייה כוללת הסכמה לניצול אחוזי הבנייה, בהיקף הנדרש לשם מימוש זכות הבנייה שהוקנתה.

הפרשנות המוצעת על ידי נתבעות 9 ו-10 ולפיה בהעדר התייחסות התקנון לשיעור אחוזי הבנייה המוקנים לתובעת לשם בנייה על הגג, יש לחשב את זכויות הבנייה על-פי חלקה ברכוש המשותף, אינה מתיישבת עם ההלכה המחייבת, ומעבר לכך, מביאה לתוצאה המעקרת את לשון התקנון מתוכן.

כלל הוא במלאכת פרשנות החוזה, שאין לייחס לחוזה פרשנות שאינה מתיישבת עם לשונו, וחזקה היא, שפרשנות החוזה תואמת את המשמעות הפשוטה העולה מקריאת לשון החוזה (דנ"א 8100/19 **ביבי כבישים עפר ופיתוח בע"מ נ' רכבת ישראל בע"מ** (נבו, 19.4.2020); ע"א 702/80 גלפנשטיין נ' אברהם פ"ד לז(4) 113)). על-פי לשון התקנון, ניתנה לתובעת זכות להקים מבנה או מבנים על כל שטח הגג או על חלק ממנו וכן לצרף את המבנה או המבנים החדשים לתשתית המים והחשמל של הבניין. מלשון סעיף 2 לתקנון עולה כי מדובר בתוספת בנייה משמעותית, שיכולה להשתרע על שטח הגג כולו, ובכוחה להשפיע על חלקו של כל אחד מבעלי הדירות ברכוש המשותף: **"בעלי כל הדירות מסכימים בזה כי כתוצאה מתיקון צו רשום הבית יחולו שנויים בחלקים ברכוש המשותף הצמודים לכל יחידה ויחידה".**

מעיון בפרוטוקול הוועדה המקומית מיום 30.12.2013 (ראו עמ' 3 לנספח ג' לכתב התביעה) ניתן ללמוד כי שטח הבנייה שנתר לניצול לטובת הבניין נכון לשנת 2013 עמד על 80.97 מ"ר. הואיל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/168/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

וחלקה של התובעת ברכוש המשותף הוא 8/562, יוצא שלפי מפתח חלוקה זה, שטח הבנייה העומד לטובתה הוא 1.15 מ"ר (1.15 מ"ר = 80.97 X 8/562). הפרשנות שמבקשים הנתבעים לייחס לתקנון, ולפיה לתובעת אחוזי בנייה באופן יחסי לחלקה ברכוש המשותף, מובילה כאמור לתוצאה אבסורדית, לפיה מוקנית לתובעת זכות בנייה בשטח 1.15 מ"ר בלבד. פרשנות זו אינה מתיישבת עם לשונו הפשוטה של ההסכם שעניינה הסכמה לבנייה על שטח הגג המוצמד לדירת התובעת, כולו או מקצתו, ולמעשה היא מרוקנת מתוכן את האמור בתקנון ואת הזכות שהוענקה לתובעת לבנות על הגג המוצמד לדירתה.

משברירת המחדל היא כי הצמדת שטח מסוים מהרכוש המשותף למטרת בנייה כוללת גם את הזכות לנצל את אחוזי הבנייה המוקנים לבניין, בהיקף הנדרש לצורך מימוש זכות הבנייה שהוקנתה, נדחית טענת נתבעים 2-5 בדבר זכותם לקבלת תמורה עבור ניצול זכויות הבנייה ע"י התובעת (ס' 6.6 לסיכומיהם).

אשר לטענת נתבעות 9 ו-10 בדבר העדר התייחסות בהסכם המכר לעניין שיוך אחוזי הבנייה לתובעת, ייאמר כי בתצהיר תשובותיה לשאלון הצהירה התובעת (שאלה 6) כי טרם רכישת הדירה נבדק תשריט הבית המשותף ע"י בא כוחה ואף הועברו לרשותה החלטות הוועדה המקומית בקשר לבקשה לקבלת היתר בניה על הגג. אין ממש בטענת הנתבעות 9 ו-10 כי תשובה זו אינה מתיישבת עם סעיף בהסכם המכר המסיר אחריותם של בא כוח התובעת לבדוק את "מצבה הפיזי ו/או התכנוני של הדירה ו/או את מידת התאמתה לתוכנית המדידה ו/או להיתרי הבניה...". ראשית, ספק אם עניין אחוזי הבנייה נמנה על אחד מאלו, ושנית, גם לו היה מצוין במפורש בסעיף, אין בכך לדחות את הטענה כי עניין אחוזי הבנייה היה ידוע לתובעת מראש, כפי שעולה מתשובתה לשאלה 6. משוויתרו הצדדים על קיום הליך הוכחות, אין בידי לקבוע ממצאי מהימנות ביחס לתצהיר התשובות לשאלון שהגישה התובעת, ומשכך אין לשלול את טענת התובעת בעניין זה, מה גם שעניין זה אינו מעלה ואינו מוריד בסוגיה שלפניי, לאור הנימוקים שהובאו לעיל.

עוד יש לדחות את הסתמכותן של נתבעות 9 ו-10 על החלטת רשויות התכנון לדחות את הבקשה להיתר, כראייה להוכחת טענתן במחלוקת שלפניי. סמכותן של רשויות התכנון מוגבלת לדיון בשאלות תכנוניות ובמצבים שבהם נמצא שאין למבקש זכות קניינית, מנועות הן להכריע בסוגיה זו, ועליהן להפנות את המבקש לבית המשפט המוסמך לדון בהיבט הקנייני, כפי שעשו במקרה שלפניי. (ראו: בג"צ 1578/90 אייזן נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ת"א (24.10.1990); דנ"מ 668/11 בני אליעזר בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים (24.07.2011); עע"מ 759/19 טליאט נ' ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה מחוז ת"א (נבו, 15.7.20)).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/168/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנה כי כן, מלשונו הברורה של התקנון עולה כי לתובעת ניתנה הסכמת כל בעלי הדירות לבנות על שטח הגג המוצמד לדירתה או על חלקו. בהתאם לפסיקה, הסכמה לבנייה על שטח מוצמד כוללת מאליה גם הסכמה לניצול הזכויות הנדרשות לשם מימוש זכות הבנייה שהוקנתה, ולא הוכח לפניי כי במקרה הנוכחי יש להורות אחרת.

לנוכח האמור לעיל, ובשים לב ללשון התקנון ולתכלית שעמדה בבסיס הוראותיו ולאור הפסיקה הנוהגת, התביעה מתקבלת. לתובעת מוקנית זכות לנצל את אחוזי הבנייה שנותרו לבניין, לצורך בנייה על שטח הגג המוצמד לדירתה או על חלקו, בהתאם לאמור בתקנון, ואין היא נדרשת לשם כך לקבל את הסכמת יתר בעלי הדירות. מובן כי זכותה של התובעת כפופה לקבלת היתר מרשויות התכנון.

לאור התוצאה אליה הגעתי, ראיתי לחייב כל אחת מנתבעות 9 ו-10 בתשלום הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 1,000 ₪ וכל אחד מנתבעים 2-5 בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 1,500 ₪. סכומים אלו ישולמו לתובעת בתוך 30 יום, אחרת יישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה (17.3.2019) ועד למועד התשלום בפועל.

בפסיקת סכום ההוצאות נתתי דעתי לסעד המבוקש, ולרוחב יריעת המחלוקת כפי שהוגדרה בכתבי טענות הצדדים. כן לקחתי בחשבון את התנהלות בעלי-הדין בהליך, לרבות ההסדר הדיוני שחסך זמן שיפוטי יקר.

משלא הוגש כתב הגנה מטעם נתבעים 8,6,1 ו-11 ולנוכח הודעתו של נתבע 7 כי הוא מסכים לקבלת התביעה, לא פסקתי הוצאות נגד נתבעים אלו.

מזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים.

ניתן ביום ח' בסיון תשפ"א, 19 במאי 2021 בהעדר הצדדים.

**עינת מידן
מפקחת על רישום מקרקעין**